

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/1937

הצעת חוק-יסוד : השפיטה (תיקון – רפורמה במשפט)

תיקון סעיף 4 1. בחוק-יסוד : השפיטה¹ (להלן – חוק היסוד), בסעיף 4 –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו, יבוא "אשר חבריה יתמנו בתוך 30 ימים מיום שהביעה הכנסת אמון בממשלה חדשה";

(2) במקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יבוא –

"(ב) הוועדה תהיה של אחד עשר חברים, שהם :

(1) שר המשפטים שיכהן כיושב ראש הוועדה ושני שרים אחרים שתקבע הממשלה ;

(2) שלושה חברי הכנסת שהם יושבי הראש של ועדות הכנסת הבאות : ועדת החוקה, חוק ומשפט, הוועדה לביקורת המדינה וועדת הכנסת ;

(3) נשיא בית המשפט העליון ושני שופטים אחרים של בית המשפט העליון שיבחר חבר שופטיו ;

(4) שני נציגי ציבור שיבחר שר המשפטים שאחד מהם עורך דין.

לא תתערב רשות שלטונית, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בבחירת חברי הוועדה מלבד אלו שמסורים לבחירתה, ולא תתערב בהליכי עבודת הוועדה, בשיקול דעתם של חבריה ובהחלטותיה.

(ג) בחירת שופט של בית המשפט העליון תיעשה בידי הוועדה ברוב חבריה (בסעיף זה – החלטת הבחירה) ; החלטת הבחירה תיכנס לתוקף רק לאחר החלטת אישור של הוועדה ברוב

חבריה (בסעיף זה – אישור הבחירה); בין החלטת הבחירה ובין אישור הבחירה, תקיים ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שימוע פומבי למועמד בתוך 21 ימים מיום שמסר לה שר המשפטים על החלטת הבחירה; לא קיימה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שימוע בפרק הזמן האמור, רשאית הוועדה לאשרר את הבחירה ללא שימוע כאמור.

(ד) נשיא וסגן נשיא של בית המשפט העליון יתמנו לתקופת כהונה חד פעמית בת שש שנים, באותה הדרך שבה מתמנים שופטים של בית המשפט העליון, בין אם כיהנו תחילה כשופטים של בית המשפט העליון ובין אם לאו, והם יכהנו גם כשופטים של בית המשפט העליון; נשיא או סגן נשיא שסיימו את תפקידם בטרם יצאו לקצבה, יוסיפו לכהן כשופטים של בית המשפט העליון עד צאתם לקצבה."

תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7 לחוק היסוד, בפסקת משנה (4), במקום "שבעה חברים" יבוא "תשעה חברים".

הוספת סעיף 15א 3. אחרי סעיף 15 לחוק היסוד יבוא –

"ביקורת שיפוטית 15א. (א) לא ידון כל בית משפט, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בסעד או בעניין תוקפו של חוק והתגברות בטענה הנוגעים לתוקפו של חוק-יסוד; על אף האמור בסעיף 15 ובכל דין, לא יהא תוקף לפסק דין, צו או החלטה אחרים של כל בית משפט המבטלים או מגבילים את תוקפו של חוק-יסוד או של חלקים ממנו.

(ב) בית המשפט העליון בלבד רשאי להורות בפסק דין על ביטולו של חוק שאיננו חוק-יסוד, ביטול חלק ממנו או הגבלת תוקפו, בהתקיים כל אלה:

(1) בית המשפט מצא כי החוק סותר סתירה מהותית הוראה מפורשת בחוק-יסוד;

(2) פסק הדין ניתן בהרכב של כל שופטי בית המשפט העליון, למעט שופטים שנבצר

מהם להשתתף בדיון במשך למעלה מ-30 ימים מיום שנדרש בית המשפט העליון להכריע בענין, ותמכו בהחלטה לבטל את החוק שמונים אחוזים מכלל שופטי בית המשפט העליון או יותר.

(ג) בית המשפט העליון רשאי לתת צו ביניים בעניין תוקפו של חוק שאיננו חוק-יסוד עד למתן פסק דין, אם מצא כי התקיימו כל אלה:

- (1) בית המשפט מצא כי יש אפשרות ממשית שהחוק יימצא סותר סתירה מהותית הוראה מפורשת בחוק-יסוד וכי בהיעדר צו ביניים תיגרס פגיעה חמורה ובלתי הפיכה לעיקרון המעוגן בחוק-יסוד;
- (2) בהחלטה על מתן הצו תמכו שמונים אחוזים משופטי בית המשפט העליון או יותר.

תוקפו של צו ביניים כאמור לא יעלה על חודש ימים ותוקפם המצטבר של צווי הביניים כולם ביחס לאותו החוק לא יעלה על שלושה חודשים.

(ד) קבע בית המשפט העליון בפסק דין כאמור כי חוק איננו תקף, רשאי הוא לתת הוראה או סעד יחסיים הנראים לו דרושים בנסיבות הענין, לרבות קביעה בדבר מועד התחילה של הוראת הבטלות.

(ה) כוחו של פסק-דין כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יפה רק לעניין הוראת החוק שנדונה בו והוא לא ישמש תקדים ביחס לתוקפו של חוק אחר.

(ו) בית משפט אינו רשאי להורות לכנסת לחוקק חוק-יסוד או חוק, להימנע מלחוקק חוק-יסוד או חוק, להורות על עיכוב בהליכי חקיקתם בכנסת או הכנתם על ידי הממשלה, ואין הוא רשאי למנוע פרסומם ברשומות או את

כניסתם לתוקף בכל דרך אחרת.

(ז) הורה בית המשפט העליון על ביטולו של חוק, ביטול חלק ממנו או הגבלת תוקפו, לרבות בצו ביניים, כאמור בסעיפים קטנים (ב), (ג) או (ד), וחוקה הכנסת לאחר מכן חוק זהה לו, לא יוכל בית המשפט לבטלו, כולו או חלקו או להגביל את תוקפו במשך ארבע שנים או עד חלוף שנה מיום השבעתה של כנסת חדשה לאחר חקיקת חוק כאמור – לפי המאוחר, אם נתקיימו כל אלה:

(1) החלטת בית המשפט העליון אשר ביטלה כאמור את החוק שקדם לו לא נתקבלה בהסכמת כל שופטיו;

(2) הכנסת חוקה את החוק כאמור ברוב חבריה;

(3) נאמר בחוק כי הוא יעמוד בתוקפו על אף האמור בפסיקת בית המשפט.

(ח) חוקה הכנסת חוק כאמור בסעיף קטן (ז) ובנסיבות כאמור בסעיף קטן זה וכנסת שהושבעה לאחר הכנסת שחוקה חוק כאמור שבה וחוקה ברוב חבריה חוק זהה לחוק כאמור, לא יוכל בית המשפט העליון לבטל את תוקפו, כולו או חלקו או להגביל את תוקפו – ללא מגבלת זמן.

(ט) הורה בית המשפט העליון על ביטולו של חוק, ביטול חלק ממנו או הגבלת תוקפו, לרבות בצו ביניים, כאמור בסעיפים קטנים (ב), (ג) או (ד), והחלטת בית המשפט בעניין נתקבלה בהסכמת כל שופטיו וחוקה הכנסת לאחר מכן חוק זהה לו, לא יוכל בית המשפט לבטלו, כולו או חלקו או להגביל את תוקפו אם נתקיימו כל אלה:

(1) הכנסת חוקה את החוק כאמור ברוב חבריה;

(2) נאמר בחוק ובנוסח הצעת החוק

שאושר בקריאה ראשונה כי הוא יעמוד בתוקפו על אף האמור בפסיקת בית המשפט;

(3) החוק נחקק על ידי כנסת שהושבעה לאחר הכנסת אשר חוקקה את החוק שבית המשפט העליון הורה על ביטולו.

(י) על אף האמור בסעיף 15 ובכל דין, לא יהא תוקף לפסק דין או החלטה המורה על ביטולו של חוק, ביטול חלק ממנו או הגבלת תוקפו שלא לפי סעיף זה ולא יהא תוקף לפסק דין או החלטה המורה לחוקק חוק, להימנע מלחוקק חוק או לעצור הליכי חקיקה או הליכי כניסת חוק לתוקף כאמור בסעיף קטן (ו).

(יא) התעוררה בפני שופט, הרכב שופטים או מי שבידיו סמכות שפיטה, טענה בעניין תוקפו של חוק אגב דיון בעניין המצוי בסמכותו, רשאי הוא לדחותה; מצא השופט, ההרכב או מי שבידיו סמכות שיפוטית כאמור, לרבות שופט או הרכב של בית המשפט העליון שלא כאמור בסעיף קטן (ב), כי יש לבטל חוק, כולו או חלקו, או להגביל את תוקפו, לרבות במתן צו ביניים בעניינו, יורה לאפשר לצדדים להליך להעביר את הדיון וההחלטה בשאלת תוקפו של החוק בלבד, באמצעות עתירה לביטול חוק, להרכב של בית המשפט העליון לפי סעיף קטן (ב) בטרם יסיים את הכרעתו ביתר הטענות והסעדים שבאותו עניין; בית המשפט העליון רשאי לדון תחילה בעתירה לביטול חוק בהרכב של שלושה שופטים שיהיו מוסמכים לדחות את העתירה ויעבירו את העתירה להרכב כאמור בסעיף קטן (ב) רק אם מצאו כי יש לבטל את החוק, כולו או חלקו או להגביל את תוקפו.

לעניין סעיף זה –

"חוק" – כל הוראה מתוך הצעת חוק שאישרה מליאת הכנסת במספר הקריאות הדרוש לשם חקיקתה וברוב הדרוש לשם חקיקתה ופורסמה ברשומות – ללא תלות בתכניה, במשך תוקפה או בטיב יתר ההליכים לחקיקתה;

"חוק יסוד" – כל הוראה מתוך הצעת חוק-יסוד שאישרה מליאת הכנסת במספר הקריאות הדרוש לשם חקיקתה וברוב הדרוש לשם חקיקתה ופורסמה ברשומות – ללא תלות בתכניה, במשך תוקפה או בטיב יתר ההליכים לחקיקתה.

ביטול עילת הסבירות 15ב. ביקורת סבירות שיקול הדעת של הממשלה, שריה והרשויות הכפופות לה נתונה בידי הכנסת; לא יפסול בית משפט, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, החלטה של הממשלה, שר משרה, רשות הנתונה לאחריותם או כל מי שפועל מטעמם על יסוד מידת סבירותה, תהא אשר תהא לטעמו; פסילת החלטה בסעיף זה – פסילה מלאה, חלקית או הגבלת תוקף של החלטה, לרבות החלטה על מינויו של אדם, או של הימנעות מקבלת החלטה כאמור."

הוראת מעבר 4. ועדה לבחירת שופטים כאמור בסעיף 4 כנוסחו בחוק זה, תתמנה בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק-יסוד זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לחוק יסוד זה שלוש מטרות.

האחת, לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים להרכב אשר ישקף באופן ייצוגי יותר את העמדות הרווחות בציבור, את הגיוון הערכי והחברתי בישראל ואת ציפיות הציבור ממערכת המשפט, וכן, להבטיח שקיפות בהליך מינוי השופטים.

המטרה השנייה היא להסדיר לראשונה בחוק יסוד ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית של הכנסת, להגדיר את גבולותיה, לקבוע פסקת התגברות מדורגת, ולהבטיח את ריבונות העם ואת כפיפות הרשות השופטת לשלטון החוק באמצעות הבהרת עליונות חוקי היסוד.

המטרה השלישית היא לבטל את עילת חוסר הסבירות במשפט המינהלי הישראלי כפי שהתעצבה

בעשורים האחרונים, ולהחזיר את הביקורת השיפוטית המינהלית לעילות המבוססות על אמות מידה ברורות, מוסכמות ומקובלות בעולם.

שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים והבטחת שקיפות בהליך הבחירה

מוצע לקבוע בסעיף 4 לחוק היסוד הרכב לוועדה לבחירת שופטים אשר יאפשר ביטוי רחב לערכי הציבור ולגיוון העמדות וההשקפות בחברה הישראלית, ולמנוע מצב שבו השופטים המכהנים שולטים – באופן חיובי או בדרך של וטו – בהליכי המיון והבחירה לתפקידי שפיטה, והרשות השופטת משפיעה בעצמה על הרכבה. עוד מוצע לאפשר שימוע פומבי למועמדים לבית המשפט העליון בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת באופן שיבטיח שקיפות בהליכי המינוי. השימוע יבטיח את איכות המועמדים לשיפוט ויבטיח דיון ציבורי גלוי בתפיסות המשפטיות ובערכים העקרוניים של המועמדים לפני מינויים. הרכב הוועדה לבחירת שופטים עובר לחקיקתו של חוק זה הוא בן תשעה חברים. שלושה מתוכם שופטים של בית המשפט העליון, שני נציגים של לשכת עורכי הדין, שני חברי כנסת ושני שרים. בשיטה זו לחברי הוועדה שאינם נבחרים ציבור – השופטים ועורכי הדין – יש רוב בוועדה, ולא ניתן למנות שופט שאינו מקובל עליהם לערכאה כלשהי. יתרה מכך, נציגי בית המשפט העליון בוועדה נוהגים להצביע באופן מתואם ביניהם, והדבר גורם לכך שנציגי הרשות השופטת מנהלים משא ומתן עם יתר חברי הוועדה כיחידה אחת עם כוח מיקוח מוגבר.

מדינת ישראל צריכה מערכת משפט חזקה ועצמאית, כמו כל מדינה מערבית מתוקנת. ביקורת שיפוטית שמקיים בית המשפט על מעשים שלטוניים בהכרח מושפעת מעת לעת מתפיסות עולם ערכיות של השופט. אשר על כן היא חייבת להיעשות בידי שופטים אשר משקפים בתפיסותיהם המשפטיות במידת מה את מפת הערכים העקרונית של הציבור. הכרעה שיפוטית אמנם שונה באופייה מהכרעה פוליטית ברשויות השלטון האחרות, אך גם היא צריכה להתבצע בידי פורום אשר משקף את ערכי הציבור ואת תפיסותיו. כך בייחוד לאור העובדה שבשנים האחרונות הולך וגובר עיסוקו של בית המשפט בעניינים בעלי אופי ציבורי-פוליטי.

הדברים אמורים ביתר שאת ביחס לבית המשפט העליון, לנוכח העובדה שחוק זה מסמיך אותו לראשונה לפסול חוקים שחוקקה הכנסת. רשות שיפוטית שמקבלת סמכות להתערב בהכרעותיו הערכיות של המחוקק, חייבת לבטא שיקוף רחב של העמדות הרווחות בציבור כדי להצדיק את סמכותה זו. לא בכדי, במבט משווה, ניתן לראות כי מדינות דוגמת ארצות הברית, גרמניה וקנדה, אשר מסמיכות את בתי המשפט שלהן לפסול חוקים, בוחרות את שופטי הערכאה השיפוטית העליונה שלהן באמצעות נבחרים ציבוריים. מנגד, מדינות המאפשרות לשופטים וטו על בחירת השופטים לבית המשפט העליון, דוגמת בריטניה, לא מסמיכות את בתי המשפט לפסול חקיקה ראשית.

עוד נדגיש באשר למינויים לבית המשפט העליון, כי שיטת מינוי השופטים בישראל חריגה מאוד ביחס למקובל בעולם המערבי. מחקר משנת 2019 שבדק את שיטת מינוי השופטים לערכאה החוקתית העליונה בקרב 36 מדינות ה-OECD, (בית משפט עליון או בית משפט לחוקה לפי העניין), מצא כי 24 מתוך 36 המדינות שנבחנו בוחרות את שופטיהן בשיטה שמעניקה את זכות הבחירה לנבחרים ציבוריים בלבד. כך למשל, בארצות הברית מתמנים שופטי בית המשפט העליון בידי הנשיא ובאישור הסנאט; בגרמניה שופטי בית המשפט לחוקה מתמנים בידי הרשות המחוקקת על שני בתי; בצרפת נבחרים שופטי המועצה החוקתית

בידי הנשיא ושני בתי הנבחרים בחלוקה שווה, ולצידם מכהנים גם נשיאי המדינה בעבר; וביפן הבחירה נשלטת בידי הממשלה בכפוף למנגנון אשרור במשאל עם. לשיטה של בחירה בלעדית בידי נבחר ציבור של שופטי הערכאה החוקתית העליונה שותפות גם קנדה, אוסטרליה, ניוזילנד, בלגיה, שווייץ, אוסטרליה, אירלנד, הולנד, דנמרק, שבדיה, איסלנד, פינלנד, נורבגיה ועוד. יש לציין כי גם בישראל בשנותיה הראשונות נהגה שיטה כזו והשופטים אשר יסדו את בית המשפט העליון התמנו בידי הממשלה באישור הכנסת.

רק ארבע מדינות החברות בארגון ה-OECD, פרט לישראל, ממנות את כלל שופטי הערכאה החוקתית העליונה שלהן מבלי לאפשר לנבחר ציבור לשלוט בקביעת זהות השופטים: טורקיה, יוון, בריטניה ולוקסמבורג. ואולם בריטניה ולוקסמבורג נבדלות מישראל וממרבית המדינות האחרות בכך ששופטיהן לעולם אינם פוסלים את חוקי הפרלמנט, וכך עליונות ערכי הציבור מושגת בהן באמצעות עליונות החקיקה. יוצא אפוא כי מבין כל 36 מדינות ה-OECD, חברותיה היחידות של ישראל למתן זכות וטו למי שאינם נבחר ציבור על מינוי שופטים לערכאה העליונה שמסוגלת לפסול את חוקי הפרלמנט, הן יוון וטורקיה.

מקרב 50 המדינות שמרכיבות את ארצות הברית, ב-22 מדינות נבחרים שופטי בית המשפט העליון ישירות בידי הציבור באמצעות הצבעה בקלפי; 15 מדינות נוספות מאשררות את כהונת שופטיהן בבחירה ישירה בקלפי; ארבע מדינות בוחרות את שופטיהן בידי נבחר ציבור ושמונה מדינות בידי ועדה שרוב חבריה מתמנים בידי נבחר ציבור. (לסקירת שיטת המינוי של שופטי הערכאה החוקתית העליונה ב 36 מדינות ה-OECD וב-50 מדינות ארצות הברית ראו: שי ניצן כהן, שמעון נטף ואביעד בקשי, בחירת שופטים לבתי משפט חוקתיים – מחקר השוואתי (2019)).

חוק יסוד זה איננו מעבר חד לשיטת המינוי המקובלת בעולם לערכאות העליונות אלא נוקט בדרך ביניים של הגדלת משקלה היחסי של הבחירה הדמוקרטית בהרכב הוועדה לבחירת שופטים מבלי להוציא ממנה את השופטים. כך גם נוצרת ועדה מאוזנת שמתאימה גם לבחירת השופטים בכלל הערכאות תוך שיתוף פעולה בין השופטים החברים בוועדה לבין דומיננטיות של הכרעה דמוקרטית בהרכב הוועדה, באופן שיבטיח ביטוי לערכי המגוונים של הציבור בערכאות השונות ולציפיותיו של הציבור ממערכת המשפט באופן כללי.

מוצע לקבוע משקל שווה לשלוש רשויות השלטון כאשר בוועדה יכהנו שלושה שרים, שלושה שופטים של בית המשפט העליון ושלושה ראשי ועדות של הכנסת: ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הכנסת והוועדה לביקורת המדינה. לצדם יכהנו שני נציגי ציבור שיבחר שר המשפטים כאשר האחד עורך דין והשני איננו, כדי שייצג נקודת מבט ציבורית של מי שאינו מגיע מתחום המשפטים. שני נציגי הציבור יחליפו את שני נציגי לשכת עורכי הדין שביניהם עובר לחוק. אין הצדקה לחברותם של נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה, שכן גוף זה איננו מייצג את הציבור הכללי, ואף ספק כמה הוא מייצג את ציבור עורכי הדין נוכח ההשתתפות הנמוכה בבחירות ללשכת עורכי הדין. את נציגי הציבור ימנה שר המשפטים שכן הוא זה אשר מונה בידי הכנסת להיות אמון על אינטרס הציבור בתחום המשפט. השר, כנציג עכשווי ומתחלף של הרוב, יבחר את נציגי הציבור בסמוך לכינונה של כנסת חדשה.

הרכב ועדה כזה צפוי להניב לאורך שנים מצטברות הרכב מגוון ופלורליסטי של שופטים, באופן שייצג

טוב יותר את מגוון הדעות והקהלים בישראל. במבט לאחור על זהותם של שרי המשפטים שכיחנו בישראל בעשרים השנים האחרונות ועל השקפות עולמם, ניתן לראות גיוון רב מאוד. יש בכך כדי להמחיש כיצד הרכב ועדה כזה צפוי להניב לאורך שנים מצטברות הרכב מגוון ופלורליסטי של בית המשפט. לבסוף יצוין כי כהונת ראש הוועדה לביקורת המדינה בוועדה לבחירת שופטים נועדה להבטיח סטטוטורית ייצוג קבוע של האופוזיציה בכנסת בהרכב הוועדה – עניין שלא תמיד נהג בעבר.

לבסוף מוצע לתקן את סעיף 7 ולקבוע כי כדי להדיח שופט על ידי הוועדה תהיה דרושה תמיכה של תשעה חברים במקום שבעה. זאת, כדי להבטיח כי הדחת שופט תחייב הסכמה מצד נציגי שלוש רשויות השלטון כולן.

ביקורת שיפוטית על חוקתיותם של חוקים והוראת התגברות

מטרתו השנייה של חוק יסוד זה היא לקבוע לראשונה ביקורת שיפוטית על חוקתיותם של חוקים ולהגביל אותה לאמות המידה שקובע מחוקק היסוד.

מוצע להוסיף לחוק-יסוד: השפיטה את סעיף 15א אשר יקבע מנגנון לביקורת שיפוטית על חוקים שהכנסת מחוקקת. הסעיף המוצע קובע כי בטלותם של חוקים רגילים שעומדים בסתירה לחוקי יסוד איננה אוטומטית וכי רק בית המשפט העליון, בהרכב מלא של כל שופטיו, למעט שופטים שנבצר מהם להשתתף בדיון במשך למעלה מ-30 ימים מיום שנדרש בית המשפט העליון להכריע בעניין, רשאי לדון בפסילתו של חוק. זאת, הן כדי להבטיח דיון מקיף וממצה עם מגוון העמדות שיש לבית המשפט העליון והן כדי למנוע השפעה על הדיון בשל אקראיות ההרכב שידון בו. עוד מוצע כי הרוב הדרוש לפסילתו של חוק בידי בית המשפט יהיה רוב של שמונים אחוזים מכלל השופטים המכהנים בבית המשפט העליון, מתוך תפיסה שביטול הבחירה הדמוקרטית של הציבור הוא אירוע חריג שבחריגים ואם קיים ספק שמוביל כמה שופטים להתנגד לביטולו של החוק, הרי שיש להשאיר את בחירתו הדמוקרטית של הציבור באמצעות נבחריו על כנה. עמדה זו היא גם ביטוי לעובדה בישראל טרם גובשה חוקה מלאה ומוסכמת. לפיכך, פסילת חקיקה על בסיס חקיקת יסוד צריכה להיעשות בהסכמה שיפוטית רחבה.

הצעת חוק יסוד זו תוחמת את העילות לביקורת חוקים רגילים של הכנסת לחוסר הלימה לחוקי יסוד בלבד. לצד זאת ההצעה קובעת עליונות מוחלטת של חוקי היסוד ושוללת ביקורת שיפוטית עליהם, כדי להבטיח את כפיפות בית המשפט לשלטון החוק ולמקור סמכות דמוקרטי. זאת, בדומה למרבית מדינות העולם המערבי שלא נוהגת בהן ביקורת שיפוטית על הנורמה החוקתית.

לפי ההסדר המוצע, כל רשות שיפוטית שיתעורר בפניה ספק בדבר תוקפו של חוק, תהא רשאית לדחות את הטענה. ואולם אם סבורה אותה רשות שיפוטית כי יש לבטל או להגביל את תוקפו של חוק, והיא תמצא כי לא ניתן להכריע בעניין שבפניה בלי להכריע בשאלת תוקפו של החוק, תאפשר לצדדים להעלות את השאלה ישירות לבית המשפט העליון באמצעות עתירה לביטול החוק. בית המשפט העליון יהיה רשאי לדחות עתירות שכאלה בהרכב של שלושה שופטים, ורק אם סבור בית המשפט העליון כי אין מנוס מדיון בתוקפו של חוק, ייתכנס לשם כך בית המשפט העליון בהרכבו המלא.

חוק-יסוד זה מעגן הוראת התגברות שבאמצעותה יכולה הכנסת לדחות פרשנות שנתן בית המשפט העליון לחוק היסוד או איזון מסוים שקבע בין ערכים או אינטרסים, ולהתגבר על פסיקת בית המשפט העליון הפוסלת חוק. לפי המוצע, הכנסת תהיה רשאית, בתנאים מסוימים, להתגבר על פסיקה שיפוטית

המבטלת חוק באמצעות הוראת התגברות. הרעיון שעומד ביסודה של הוראת התגברות איננו פטור של הכנסת מן המחויבות לערכי החוקה אלא מתן אפשרות למחוקק להכריע אחרת מבית המשפט בשאלה של איזון בין ערכים ובחינת שאלות המידתיות הכרוכות בהתנגשות ביניהם.

מוצע כי אם פסל בית המשפט העליון הוראת חוק בהסכמת כלל שופטיו – לא תוכל הכנסת שחוקקה אותו להתגבר על פסיקה זו של בית המשפט העליון בתקופת כהונתה.

לעומת זאת, אם פסיקת בית המשפט הפוסלת חקיקה ראשית של כנסת התקבלה שלא בהסכמת כלל שופטיו, מוצע כי הכנסת תוכל להתגבר על פסיקת בית המשפט הפוסלת חוק ברוב של 61 חברי הכנסת וזאת אם קבעה הכנסת במפורש כי החוק יעמוד בתוקפו על אף פסיקת בית המשפט. ההתגברות תהיה בתוקף עד לכהונתה של הכנסת הבאה, אשר תוכל לבחון אותה מחדש. לשם כך נקבע כי תוקף ההתגברות מוגבל למשך ארבע שנים או עד לתום שנה מתחילת כהונתה של הכנסת המכהנת לאחר הכנסת שחוקקה את חוק ההתגברות, לפי המאוחר. מודל התגברות זה, שאין בו אפשרות להתגברות מראש, מאפשר דו-שיח תקין ומועיל בין הרשויות, וכי הכנסת תראה לנגד עיניה את פסק דינו המנומק של בית המשפט בטרם תחליט לנקוט בצעד חריג של התגברות.

כמו כן, מוצע כי הכנסת תוכל להתגבר גם על פסיקה לביטול חוק שנתן בית המשפט פה אחד, אולם רק אם הכנסת שחוקקה את הוראת ההתגברות היא כנסת שונה מזו שחוקקה את החוק שנפסל בידי בית המשפט, באופן המבטא תמיכה של שתי כנסות שונות בהכרעה הערכית המנוגדת לזו של בית המשפט. העובדה שהציבור מביע את עמדתו בתווך באמצעות בחירות כלליות, שמדובר בשיקול דעת ערכי של שתי כנסות שונות ושהתמריץ השלילי לחקיקה מידית מנוטרל, מצדיקה להשיב את ההכרעה הסופית לעם ולנבחריו. במקרה כזה, כמו גם במקרה שבו נחקקה הוראת התגברות רגילה בשתי כנסות שונות, הוראת ההתגברות תהיה קבועה.

ביטול עילת חוסר הסבירות

לבסוף מוצע לקבוע בסעיף 15ב ביטול של עילת חוסר הסבירות שהתפתחה בפסיקה הישראלית. הממשלה מחויבת לפעול לפי חוק בגבולות הסמכות שניתנה לה ובהליך הוגן. אולם הפסיקה הישראלית פיתחה בעשורים האחרונים עילת התערבות חריגה במעשי הממשלה כל אימת שבית המשפט סבור כי החלטת הממשלה או השר איננה סבירה. כפי שהזהיר בשעתו נשיא בית המשפט העליון משה לנדוי המנוח, באמצעו את עילת חוסר הסבירות שם בית המשפט עצמו בנעליה של הרשות המבצעת והחליף את שיקול דעתה (ראו: בג"ץ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור, לה(1) 421, (1980)). כתוצאה מאימוץ עילת הסבירות כעילה לפסילת שיקול דעתו של בעל הסמכות החוקית, יועצים משפטיים מתערבים תדיר בשיקול הדעת שהמחוקק הפקיד בידי הממשלה ושריה בכל סוג של החלטה או מינוי.

ביקורת סבירות שיקול הדעת של הרשות המינהלית מסורה לכנסת שנותנת אמון בממשלה ולציבור שבוחר בה, והיא אינה עניין להכרעה שיפוטית. בית המשפט מעולם לא קיבל סמכות להחליף את שיקול דעתן של רשויות השלטון האחרות ואין להניח ששיקול דעתו נכון יותר. עילה עמומה שכזו אף פוגעת בוודאות המשפטית והיא פותחת פתח לפסיקה שאיננה עקבית. בכך היא פוגעת באמון הציבור שעלול לקבל את הרושם שענייניו המשפטיים כפופים להכרעה סובייקטיבית באופיה. היא גם מתמרצת הצפה של בתי המשפט בעתירות שעניינן הימור על עמדתו הסובייקטיבית של השופט. לפיכך מוצע לבטל את עילת

חוסר הסבירות ולהחזיר את הביקורת השיפוטית על מעשי המינהל למיקוד הראוי לה בשאלות של חוסר-סמכות, תקינות ההליך ועמידה בדרישות חוקים מפורשים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)